

1503241-40.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... usuária de drogas e já foi investigada no tráfico e no uso. O atual companheiro dela, Rafael, já foi investigado e preso, mas se trata de usuário contumaz de crack. Luan não é usuário de crack e estava para a realização e o comando do tráfico. Pelo que entendeu, Luan seria o cabeça do tráfico (tanto que o dinheiro foi apreendido com a companheira dele); quanto a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503241-40.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503241-40.2021.8.26.0302 - Controle 2021/001637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO ROSA e outros

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230534/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19824002 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4737/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2230534 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Juiz de Direito: Dr. PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

GUSTAVO ROSA, RODRIGO FERNANDO ZANIN e LUAN HENRIQUE BARBOSA BELOTTO foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material (CP, art. 69), porque, em período incerto, ao menos desde julho de 2021 até o dia 24/08/2021, associaram-se, de maneira estável e duradoura, para promoverem o tráfico de drogas (eles guardavam as drogas no interior da residência [de propriedade da mãe de Gustavo] e as comercializavam aos usuários que fossem até o local, sem que existisse uma divisão de tarefas entre eles; para facilitar a venda das substâncias, eles permitiam que os usuários consumissem drogas no local); assim, aos 24/08/2021, Policiais Civis (os quais tinham a informação de que na casa de Gustavo [Rua João Pacheco de Almeida Prado Filho, nº 115, Vila Brasil, nesta cidade] ocorria o tráfico de drogas) realizavam diligências e observaram vários usuários (Rafael F.P., Natália B.V., Janaína M. e Caroline O.S.) no local e, ainda, notaram que João F.N. (usuário) estava sendo atendido por LUAN, o qual, ao perceber a presença policial,

arremessou um objeto na rua; João foi abordado e disse que estava no local para comprar crack, que normalmente era vendido por GUSTAVO e LUAN; concomitantemente, outros Policiais Civis, após a autorização de Natália (moradora do imóvel), ingressaram no interior da residência, onde estavam GUSTAVO, RODRIGO, LUAN e Rafael; houve uma busca no local e, sobre um sofá que estava na sala, foi localizado um pote contendo 20 pedras de crack; o objeto dispensado por LUAN também foi encontrado, no qual tinha mais 3 pedras de crack (as 23 porções de crack totalizaram 1,28g); no imóvel também foram apreendidas tesoura, lâmina e faca (todos com resquícios de cocaína [fls. 322/329]), além da quantia de R\$ 74,00 em dinheiro (notas fracionadas [fotos de fls. 30/31]). Formalmente interrogado, GUSTAVO disse que autorizou que os Policiais entrassem na sua residência, de propriedade de sua genitora; é usuário de crack e não vende drogas; há aproximadamente três semanas autorizou que Luan, a esposa dele e a filha passassem a residir no local; há pelo menos uma semana tomou conhecimento de que Luan estava vendendo drogas na residência, razão pela qual mandou que ele deixasse o local, mas ele não obedeceu; outras pessoas, com a sua anuência, costumam ir até a sua residência para usar crack; consome drogas com tais pessoas, mas não vende para elas; algumas porções de crack, de propriedade de Luan, foram localizadas em sua residência; não recebeu qualquer valor em contrapartida pelo uso de sua residência como ponto de tráfico de drogas; Luan já lhe entregou crack para usar (fls. 17). Por sua vez, LUAN disse que nunca vendeu drogas na residência de Gustavo e não está associado a ele ou a qualquer outra pessoa; na data dos fatos, estava no quarto do imóvel quando foi até o portão para atender uma pessoa que o chamava, ocasião em que notou que o indivíduo estava sendo abordado por Policiais; algumas pedras de crack foram localizadas na residência, as quais pertenciam a Rodrigo; não vende drogas e muito menos jogou qualquer porção de crack no telhado da casa ao avisar os Policiais; Gustavo, Rafael e Natália estavam usando crack na residência; não forneceu qualquer porção de crack para eles (fls. 19). Por fim, RODRIGO aduziu que costuma de ir na casa de Gustavo para fumar crack; Policiais ali chegaram e, autorizados por Gustavo e Natália, entraram na residência e localizaram um potinho, no qual continha diversas pedras de crack; comprou as pedras de crack de um traficante na linha do trem; a droga era para o seu consumo e não para a venda; nunca comprou drogas de Gustavo ou de Luan (fls. 20).

Os réus foram detidos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva, aos 25/08/2021 (fls. 159/163). Depois, por meio de habeas corpus, GUSTAVO e LUAN obtiveram a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares (fls. 197/202, 226/230, 281/291 e 304/314), o que foi cumprido em 01/09/2021 (fls. 213/215 [Gustavo]) e aos 03/09/2021 (fls. 246/248 [Luan]). Durante a audiência de instrução (fls. 535/541 [15/03/2022]), por decisão deste r. Juízo, foi revogada a prisão preventiva do réu RODRIGO, sendo o alvará de soltura cumprido em 16/03/2022 (fls. 548/550).

Regularmente notificados (fls. 346, 359 e 383), GUSTAVO e RODRIGO ofereceram resposta escrita conjunta à acusação (fls. 360/362), enquanto LUAN ofereceu-a distintamente (fls. 382), após o que a denúncia foi recebida, em 24/01/2022 (fls. 384/386).

Em instrução (audiência virtual realizada por meio de videoconferência - ferramenta Microsoft Teams), ouviram-se testemunhas, interrogando-se os réus ao final. Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou pela parcial procedência da ação penal, com condenação do acusado Luan apenas pelo delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, absolvição de Gustavo e desclassificação do delito perpetrado por Rodrigo para o crime do artigo 28 da mesma lei.

A Defesa de Rodrigo e Gustavo postulou, quanto ao primeiro, a absolvição do delito de associação para o tráfico e a desclassificação quanto ao crime ao crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, para o do artigo 28 da mesma lei, e, quanto ao segundo, a absolvição por ambos os delitos.

A Defesa de Luan, em essência, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação de tráfico para o crime de posse de droga para uso próprio e, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando-se a pena no regime aberto e recurso solto (fls.

553/638).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelos autos de reconhecimento pessoal (fls. 10), de exibição e apreensão (fls. 27/28) e de constatação provisória de substância ilícita (fls. 29), pelas fotografias das porções de droga e objetos apreendidos (fls. 30/31) e, sobretudo, pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 268/272 [crack]) e de objetos relacionados ao tráfico (fls. 322/329 [tesoura, faca, lâmina e 1 eppendorf vazio [todos com resquícios de cocaína]]).

Autoria e elemento subjetivo, contudo, parcialmente inequívocos.

O Investigador de Polícia Cleiton contou que recebeu várias informações de moradores do bairro Santo Antonio, local em que já residiu, noticiando o tráfico de drogas na casa do réu Gustavo; diligenciou no local e observou a movimentação de usuários de drogas; um informante lhe disse que outra pessoa (que sempre usava camisa de time de futebol, tinha cabelo pintado e filho pequeno) auxiliava Gustavo no comércio de drogas; depois tal pessoa foi identificada como sendo o réu Luan; realizava campanha no local, junto com outros Policiais, quando avistou um usuário de drogas batendo palmas no portão da residência, ocasião que tal indivíduo foi atendido por Luan, o qual entrou na residência e logo depois saiu com alguma coisa em sua mão; abordaram João (usuário), o qual estava na calçada e disse que tinha ido até o local para comprar droga, pois já havia adquirido em outras oportunidades; Luan correu e jogou o objeto que trazia consigo no telhado do imóvel; a moradora Natália abriu o portão e autorizou a entrada na residência; na sala foi localizado um pote contendo pedras de crack; no local estavam os três réus, além de Rafael; no telhado do imóvel foi encontrada mais droga; Rafael disse que estava no local para adquirir droga; quem entregava as drogas eram os réus Gustavo e Luan; já o réu Rodrigo estava na sala do imóvel, junto com os corréus, e assumiu a propriedade das drogas encontradas no pote, mas não o tinha visto no local antes deste fato; já tinha visto Rodrigo em outras biqueiras, pois, ao que tudo indica, ele é usuário e provavelmente assumiu a propriedade das drogas para tentar livrar os demais; fazia de dois a três meses que ocorria o tráfico no local (fls. 445/447).

O PC Basso mencionou que o Policial Cleiton tinha informação de um tráfico acontecendo em uma casa no bairro Santo Antônio. Chamou a testemunha para acompanhá-lo. Chegando ao local, presenciaram uma pessoa, provável usuário de droga, em situação típica de aquisição de entorpecente. Abordaram esse usuário, que de imediato confessou que estaria ali para aquisição de droga. No momento da abordagem, ele estava sendo atendido por um rapaz com cabelo loiro. Essa pessoa entrou correndo para casa e arremessou algo em cima da casa. Nesse ínterim, uma pessoa que estava na casa abriu o portão e autorizou a entrada dos policiais. Encontraram outras pessoas dentro da casa. Esse rapaz de cabelo loiro que estava vendendo droga foi identificado como o réu Luan. No telhado, havia o entorpecente que jogou no telhado. Havia também um pote de entorpecente com Rodrigo. Cleiton, quando comentou que lá era um local de tráfico, ele falou do dono da casa (Gustavo Rosa). Luan negou que a droga fosse dele, mas a testemunha viu ele arremessando o conteúdo no telhado. Gustavo Rosa disse que não tinha tráfico na casa dele. Rodrigo falou que a droga era para uso dele; porém, com ele foi encontrado um plástico com entorpecente. Pelo que se recorda, o usuário afirmou que naquela ocasião estava no local para comprar droga. Natalia, que abriu o portão, disse que estava lá para comprar droga, e que comprou de alguma das pessoas que estavam lá (mas não se recorda de quem). Não conhecia Luan dos meios policiais. Com João foi encontrado dinheiro e, pelo que se recorda, ele estava com uma mochila nas costas, provavelmente porque iria trabalhar. João, a princípio, ficou assustado, mas, de imediato, confirmou que entrou para comprar droga. Nesse momento, a porta da casa estava fechada; abriu quando Luan retornou para dentro da casa. Bateram na porta, e Natalia apareceu e autorizou a entrada. A abordagem da polícia quanto a João foi bem na frente da casa. Depois, soube que Natalia não morava lá, mas frequentava a

casa regularmente. Lembra-se que na casa estavam Natalia, seu marido, a esposa de Luan, uma criança. Talvez tivessem mais pessoas, mas não se recorda. A casa estava muito bagunçada. Não tem conhecimento de investigação quanto a Gustavo e Rodrigo. O PC Balduin, Investigador-chefe da DISE, narrou que, na ocasião dos fatos, vinham ocorrendo denúncias de que a casa estava sendo utilizada no tráfico de drogas, bem como no consumo. Cleiton também assim confirmou. Estavam diligenciando no bairro que é próximo à delegacia e, passando pelo local, avistaram um usuário de drogas encostar na casa de Gustavo, dando a entender que realizaria a compra de entorpecente. Resolveram abordar o indivíduo, que era João, que não chegou a realizar a compra porque a pessoa veio atender no portão (Luan) teria arremessado porção de drogas para o lado de fora da residência (posteriormente localizada pela equipe da DIG). Diante disso, pediram autorização para quem estava na residência, e foram autorizados a entrar por uma das pessoas que eram a Natalia e Gustavo. Na sala, onde estavam todas as pessoas, e no sofá onde estava Luan, Rodrigo e Gustavo, foi encontrada outra porção de crack. Segundo consta, Rodrigo teria assumido a propriedade da porção. Natalia é conhecida por ser usuária de drogas e já foi investigada no tráfico e no uso. O atual companheiro dela, Rafael, já foi investigado e preso, mas se trata de usuário contumaz de crack. Luan não é usuário de crack e estava para a realização e o comando do tráfico. Pelo que entendeu, Luan seria o cabeça do tráfico (tanto que o dinheiro foi apreendido com a companheira dele); quanto a Gustavo, inclusive o próprio usuário de drogas reconheceu-o como sendo as pessoas que realizavam o tráfico no local; Rodrigo assumiu a outra porção de crack que existia ali, dando a entender que os 03 estariam agindo no local. Apesar da pouca quantidade de droga que foi apreendida, envolvia pessoas que consomem entorpecente e, para manter o vício, realizam a venda (casos do Gustavo e Rodrigo); Luan não é usuário, mas pratica o comércio. João disse que já havia comprado algumas vezes no local. Não havia denúncia de Luan com relação a essa residência. Não teve aparência de ser uma casa abandonada. Nos dias que antecederam os fatos tomaram conhecimento que Luan estava no local; ele morava lá há cerca de 1 semana.

Janaína M. aduziu que pediu um copo de água para Gustavo e entrou na casa, oportunidade na qual a polícia chegou. Não viu ninguém usando droga, nem se Gustavo é usuário. Não sabe se Rodrigo estavam no local. Não sabe se Luan morava na casa. Não sabe se alguma pessoa assumiu a droga que foi encontrada. Acredita que Gustavo tenha autorizado a entrada das pessoas.

Natália B.V. disse que estava na casa de Gustavo, com os demais corréus quando a polícia chegou. Quando ouviu barulho de carro na rua, Luan passou correndo e jogou alguma coisa no telhado. Na oportunidade, brincou com ele e disse "olha, vai entrar em" (mas não imaginou que seria a polícia). Logo depois bateram no portão e avisou Gustavo; esse disse para Natalia abrir o portão porque era a polícia. Então, a testemunha abriu o portão. Os policiais entraram e começaram a fazer as buscas na casa. Foram direto para a sala e revistaram os meninos. Não foi encontrado nada até então. A mulher de Luan possuía algum valor em dinheiro. Rodrigo estava dormindo em um sofá (ele estava drogado há dias). Quando ele levantou, foi encontrado um pote com uma quantidade de crack. Foram todos algemados e levados à delegacia. Nesta, cada um prestou seu depoimento. A casa é de Gustavo e lá ia com frequência para usar crack. Nela morava Gustavo, mas lá via bastante dormir Luan, a menina dele. Rodrigo estava usando a casa também para trabalho. Rodrigo tinha o trabalho de tatuador. Quando ia consumir droga lá, comprava crack do Luan. A maioria das vezes comprava droga com ele, e ia usar na casa. Gustavo não vendia droga; ele oferecia a casa para as pessoas usarem. Não tem conhecimento de Rodrigo vender droga. Comprava droga de Luan há cerca de 04 ou 05 meses, e comprou no máximo umas 10 vezes. Ele vendia droga para outras pessoas que iam nessa casa também. Quando os policiais entraram na casa, não estava sob efeitos de droga. Seu companheiro é Rafael, e também não estava sob os efeitos de entorpecente. Autorizou a polícia a entrar na casa.

A testemunha Wellington afirmou que conhece o réu Luan. Já ouviu dizer que ele era usuário, mas nunca sobre a venda de entorpecente.

Interrogado em juízo, RODRIGO negou os fatos descritos na denúncia. Disse que foi à

casa de Gustavo usar entorpecente. Ficou lá cerca de 15 ou 20 minutos quando a polícia lá compareceu. A droga que foi encontrada consigo era para uso (um potinho com pedaços de entorpecentes). Conhece Gustavo através do uso de droga, e não tem conhecimento que ele faça o comércio. Já encontrou com Luan cerca de 03 ou 04 vezes, perto de pessoas que usam droga, mas nunca o viu vendendo. Não viu polícia encontrando outra droga além da sua, nem no telhado. Já viu Luan apenas usando cocaína. Não confirma como sendo sua quaisquer das drogas de fl. 31.

Interrogado em Juízo, GUSTAVO disse que não eram 23 porções de crack. A polícia foi até seu portão, pediram para entrar e a testemunha disse que Gustavo abriria, mas uma menina já o abriu. A polícia falou "para com essa bagunça na rua porque senão irei te prender". Estava fazendo do local um fumódromo. Por causa do vício, permitiu que pessoas entravam na casa para utilizar entorpecente. A polícia então estava saindo da casa, quando Rodrigo, que estava sentado em uma poltrona, levantou e a polícia viu que havia um potinho onde ele estava. Viram que era droga e prenderam todos. Negou qualquer envolvimento nos crimes imputados, aduzindo que somente é usuário de crack. A droga que Rodrigo estava era para uso dele. Luan estava no quarto dos fundos. Não viu se ele jogou alguma coisa no telhado. E os policiais também não viram, porque eles foram bem firmes, pois já estavam virando as costas para irem embora quando encontraram a droga com Rodrigo. Permitiu que Luan ficasse em sua casa até que encontrassem uma casa para a família dele (esposa e filho); porém, eles não moravam mais lá. Na polícia, falou que a droga era de Luan porque a polícia disse que assim o liberaria. Luan era usuário, de vários entorpecentes (maconha, cocaína, crack).

LUAN também negou envolvimento nos crimes. Tinha umas roupas na casa de Gustavo e, no dia, foi buscá-las. Anteriormente, diversas vezes já tinha ido ao local usar entorpecente. Quando estava pegando as roupas, estava sentado na porta, e apareceu João, que lhe pediu água. Logo em seguida, porém, a polícia compareceu. Em razão de ter visto a viatura, saiu correndo para o fundo. Não tinha droga; a única que tinha era a que estava com Rodrigo, que ele tinha pegado apenas para ele usar. Pelo que sabe, Gustavo não deixava as pessoas dormirem no local. Nunca chegou a morar um tempo lá; apenas ficava lá de dia. Nunca ficou sabendo que Gustavo ou Rodrigo têm envolvimento com o comércio de entorpecente. Não é verdade que jogou invólucro em cima do telhado, nem que João foi lá comprar droga ou que vendeu para ele. Afirmou, após, que ficou cerca de um ou dois dias na casa de Gustavo, porque estava na rua. Pois bem.

Como se vê, o conjunto probatório demonstrou que ao menos Luan praticava o crime de tráfico de drogas, pois a versão apresentada por ele, afora evidentemente inconsistentes de per si e contraditória com aquela prestada na fase policial (ocasião em que admitiu que residia na casa de Gustavo), o que enfraquece substancialmente a sua versão judicial, a qual permaneceu isolada nos autos, mormente pela isenta prova reproduzida sob o contraditório. Vale dizer, porque os Policiais Civis confirmaram toda a dinâmica da ocorrência retratada pela denúncia, inclusive de que Luan foi atender João, usuário de drogas, entrou na residência e quando retornou ao portão, avistou os Policiais e correu para o interior do imóvel, ocasião em que dispensou as porções que trazia consigo (as quais foram localizadas no telhado do imóvel).

Observe, ainda, que os depoimentos dos Policiais Civis estão corroborados pela fala da testemunha N., a qual afirmou que Luan entrou correndo no imóvel e jogou alguma coisa no telhado, tendo ela ainda admitido que havia comprado drogas de Luan por umas 10 vezes e pelo período de 4 a 5 meses, esclarecendo, ainda, que ele vendia drogas para outras pessoas que frequentavam o imóvel.

Ademais, embora não tenha sido possível a oitiva judicial do usuário João, sua fala na fase policial (fls. 7 [... já comprou drogas naquela casa em outras oportunidades, sendo atendido normalmente por um rapaz de cabelos tingidos de loiro, com tatuagem no pescoço, que identificou como sendo o réu Luan [v. fls. 10 c/c fls. 71]) viu-se corroborada, de certo modo, como se percebe, pelos relatos anteriores, reproduzido sob o contraditório e ampla defesa.

Considere-se, no mais, que a apreensão de dinheiro na posse da mulher (esposa/companheira) de Luan (segundo o PC Balduin e a testemunha Natália) sem

comprovação de origem lícita (R\$ 74,00 [notas variadas, de R\$ 2,00, R\$ 5,00 e R\$ 20,00]) e de objetos relacionados ao tráfico (faca, tesoura e lâmina, todos com resquícios de cocaína [fls. 322/329]), além da dinâmica da ocorrência (os Policiais Civis observaram a movimentação de vários usuários de drogas no local; um deles estava sendo atendido por Luan, o qual, ao perceber a presença policial, correu e arremessou um objeto [no qual continha 3 pedras de crack] no telhado do imóvel), bem como as denúncias informais apontando o local como ponto de venda de drogas convergem à conclusão de que, ao menos, Luan realizava mesmo o tráfico de drogas. Ressalte-se, ainda, que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Ademais, confira ainda esta pontual lição doutrinária: Todavia, nem sempre é possível a prova direta desses fatos específicos, ora porque foram clandestinos, ora porque são subjetivos, ora porque a prova direta pereceu ou é impossível. Nesses casos o labor probatório se desenvolve com prova indireta, cujo objeto são fatos que não estão previstos na lei com geradores de consequências jurídicas, mas que podem levar à conclusão sobre a existência daqueles fatos legalmente relevantes para se alcançar o resultado pretendido. Esses fatos, objeto da chamada prova indireta, são os indícios, que se conceituam como fatos ou circunstâncias de fato que podem levar à conclusão da existência de outros fatos. [...] verifica-se que entre a prova do indício e a convicção da existência do outro fato, o juiz, mentalmente, dá um salto, através de um raciocínio lógico, mediante a aplicação de 'presunções' ou 'regras de experiência'. [...] No primeiro caso, a convicção da existência resulta de imposição legal. No segundo, da aplicação de uma regra que o juiz extraiu da observação técnica ou da observação do que ordinariamente acontece no comportamento humano. [...] As regras de experiência, comum ou técnica, não estão no plano dos fatos e, portanto, do ônus da prova, podendo e devendo o juiz aplicá-las de ofício, como faria com as presunções legais, podendo, contudo, a parte ter interesse em desenvolver atividade argumentativa sobre tais regras, como faria juntando pareceres jurídicos sobre a interpretação do direito, mas nesse caso não se trata, propriamente, de atividade probatória, mas apenas de atividade dialética de argumentação e colaboração. [...] As presunções que decorrem das regras da experiência, quer a técnica, quer a comum, admitem prova em contrário, ou seja, as partes podem pretender demonstrar que certo fato não tem o significado que parece ter ou que ordinariamente teria. Todavia, o ônus de demonstrar essa peculiaridade é de quem pretende desfazer a conclusão que naturalmente decorreria. [...] (GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 208, 209 e 211 e 212).

Assente-se que o tipo penal analisado (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) descreve várias condutas, sendo classificado como misto alternativo, ou seja, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos-tipo para que o delito se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020 - destaquei).

Observe-se, ademais, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma injusta incriminação, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Civis que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado a respeito na nota de rodapé, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade (STJ, AgRg no RESp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em

06/10/2020).

Por outro lado, a simples alegação de que Luan seria (somente) usuário de droga não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. No mesmo rumo: [...] a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Já quanto ao réu Rodrigo, tudo converge para a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, pois a afirmação dele no sentido de que as porções de crack seriam destinadas ao uso próprio não foi seguramente ilidida pela prova acusatória, inclusive porque o PC Cleiton disse que não o tinha visto no local antes do fato aqui tratado, esclarecendo que ele é usuário, pois já o viu em outras biqueiras. Já a testemunha N. disse que Rodrigo é usuário e estava drogado, deitado no sofá, quando da diligência policial, tendo ela dito não ter conhecimento que ele vendesse drogas. Ademais, as denúncias apontavam a residência de Gustavo e o envolvimento de Luan no tráfico, nada sobre a participação/envolvimento do corréu Rodrigo.

Portanto, havendo dúvida relevante sobre a finalidade de parte da droga apreendida, deve ser operada a pretendida desclassificação em razão do princípio in dubio pro reo, mas cabendo aqui prosseguir, pois, apesar do art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal e tecnicismos à parte, é que o melhor se ajusta e convém, mormente, aos princípios da economia e celeridade processuais.

Contudo, observo desde já que Rodrigo não demonstra mérito nem à transação nem ao sursis processual (v. FA de fls. 114/130 [reincidente {furto, roubo e embriaguez ao volante}], além de ter outra condenação por crime grave [roubo], conforme certidões de fls. 108/113)).

Entretanto, considerando o tanto já cumprido da necessária prisão provisória, tenho como o mais suficiente e eficaz ao caso aplicar somente a pena de advertência (art. 28, I).

Prosseguindo, em relação a Gustavo, embora a prova colhida na fase extrajudicial esteja a indicar que tinha conhecimento e até realizava o tráfico em companhia de Luan, o realmente relevante, para os presentes fins, é que nada mais há, produzido sob o contraditório, indicando que as drogas apreendidas (que foram dispensadas por Luan e encontradas no telhado do imóvel) terem tido relação efetiva com ele (Gustavo). Ademais, ao que tudo indica, a residência de Gustavo era utilizada como "fumódromo", como ele mesmo admitiu (durante o interrogatório) e foi confirmado pela testemunha N. Necessário era, então, que se tivesse demonstrado durante a instrução processual que o réu Gustavo efetivamente aderira e atuava ou participava dos atos praticados por Luan, já que não basta mero conhecimento e/ou conivência com os atos de terceiros para a configuração do crime (conduta - dolo). Por isso e neste caso, Gustavo deve ser contemplado com o secular princípio da dúvida, que rege a causa penal nesta fase processual.

Diante disso tudo, não há que se falar na caracterização do delito de associação ao tráfico, o qual não ficou seguramente comprovado pela prova reproduzida em Juízo, conforme acima exposto. Nesse rumo: ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - [...] - Conjunto probatório inapto à manutenção da condenação - Prova acusatória

insuficiente à comprovação de ligação estável do recorrente com os demais réus - In dubio pro reo - Decretação da absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP - Recurso provido, com expedição de alvará de soltura. (TJSP - Apelação Criminal 1500310-97.2018.8.26.0228 - Relator: Newton Neves; 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2021).

Renato Marcão, quanto ao delito de associação ao tráfico, ensina o seguinte: "Não basta, não é suficiente (...) a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável". É, ainda, "necessário que se identifique, na societas criminis, o caráter permanente, que não se confunde com a mera coautoria" (TÓXICOS - Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de drogas. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 172).

Sendo assim, quanto ao crime autônomo de associação, todos os réus também devem ser contemplados com as consequências da dúvida.

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-

87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor somente a condenação de Luan pelo crime de tráfico de drogas, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade em razão da natureza da droga apreendida (crack), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Diante disso, a pena-base reclama ser exasperada, razão pela qual fixo-a em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e ao pagamento de 571 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do réu.

Na segunda fase, em virtude da menoridade relativa (CP, art. 65, I, 1ª parte) de Luan, aplico o decréscimo de 1/6, como o mais proporcional ao tanto e qualidade da atenuante reconhecida, mas sem repercussão prática em razão do entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena a serem aplicadas, nem sequer a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois a prova também deixou fora de dúvida não ter se tratado de um tráfico isolado, episódico ou mesmo incipiente a visa o benefício legal. Lembre-se de que se tratou de um tráfico de substância mais deletéria (crack) e que já era realizado há vários meses (de 4 a 5), conforme informou uma das testemunhas, a qual ainda disse que já havia adquirido droga de Luan por várias vezes. Portanto, o réu se dedicava exclusivamente à atividade criminosa do tráfico de drogas (delito fomentador de toda uma rede de criminalidade). Saliente-se, ainda, que tal benesse deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder (TJSP - Apelação Criminal nº 0002486-09.2007.8.26.0326; Relator: Luiz Antonio Cardoso; 3ª Câmara de Direito Criminal; julgamento: 25/05/2010), de modo a prestigiar o indivíduo neófito no mundo do crime e para que a este não regresse, o que, repita-se, não é o caso aqui tratado.

Nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, o réu (Luan) deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto (CP, art. 35), até porque é o que atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso, destacando-se o analisado na dosimetria como um todo.

Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, o dinheiro e

os objetos apreendidos neste processo devem ter o perdimento decretado.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de:

a) GUSTAVO ROSA, qualificado nos autos, para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, das imputações dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06;

b) RODRIGO FERNANDO ZANIN, qualificado nos autos, para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e, desclassificando a imputação do art. 33, caput, da mesma lei, então condená-lo, como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, que, considerando os princípios antes invocados e o tempo cumprido da necessária prisão provisória, dou por aplicada desde já, julgando-a extinta pelo cumprimento;

c) LUAN RODRIGO BARBOSA BELOTTO, qualificado nos autos, para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, mas para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Respondendo a este processo em liberdade por r. decisão do E. TJSP e deste Juízo, reconheço a todos os réus o direito de assim permanecerem em caso de apelação. Decreto ainda o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que os réus Gustavo e Rodrigo são assistidos pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe. Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 25 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA